

《【문제1】 다음 질문에 답하십시오. (50점)

(단, 행정쟁송법과 무관한 노동법적인 쟁점에 대해서는 서술하지 말 것.)

(물음1) A회사에 근무하는 근로자 甲은 사용자와의 임금인상에 관한 문제를 해결하고 근로조건 개선에 도모하고자 A회사에 노동조합을 조직하고 관찰시장 乙에게 설립신고서를 제출하였다. 이에 관찰시장 乙은 A회사 노동조합 설립신고서에는 'A회사로부터 해고되어 노동위원회에 부당노동행위의 구제신청을 하고 중앙노동위원회의 재심판정이 있기 전의 자'를 조합원으로 가입시킬 수 있다고 명시되어 있고, 이는 「노동조합 및 노동관계조정법」 제2조 제4호 라목의 '근로자가 아닌 자의 가입을 허용하는 경우'에 해당한다는 이유로 甲의 설립신고서를 반려하였다. 관찰시장 乙의 설립신고서 반려행위에 대하여, 취소소송을 통한 권리구제 방안을 논하십시오. (35점)》

<문제1의 물음1> 노동조합 설립신고 반려처분에 대한 취소소송상 소송요건과 가구제 및 본안 인용 시 권리구제 방안

I. 문제의 제기

- 사안에서 甲은 노동조합 설립신고를 하였으나 관찰시장 乙은 설립신고서가 노동조합 및 노동관계조정법(이하 '노조법')상 근로자가 아닌 자의 가입을 허용한다는 이유로 설립신고서를 반려하였고, 甲은 이에 대하여 취소소송을 제기하고자 한다. 쟁점으로 <관찰시장 乙의 설립신고서 반려행위가 취소소송의 대상이 되는 처분에 해당하는지 및 이를 통한 권리구제가 가능한지> 검토할 필요가 있다. 이하에서는 관찰시장 乙의 설립신고서 반려행위에 대하여 취소소송을 통한 권리구제 방안을 논한다.

II. 설립신고 반려의 처분성 및 구제수단 법리

1. 소송요건의 충족 여부

(1) 대상적격 (반려행위의 처분성)

- 노동조합 설립신고는 수리를 요하는 신고이다. "판례"는 설립신고 반려가 노동3권의 실질적 행사를 가로막고, 법적 지위 획득을 저지하는 직접적인 불이익을 초래하므로, 행정소송법상 처분성이 인정된다고 본다.

(2) 원고적격 및 소송당사자능력

- 설립등기 전 노동조합은 비법인사단으로서 소송당사자능력이 인정된다. 또한, 반려처분의 직접 상대방인 노동조합(또는 대표자 甲)은 처분의 취소를 구할 법률상 이익이 인정되어 원고적격을 구비한다.

2. 임시적 구제수단 (가구제)

(1) 집행정지 [행정소송법 제23조]

- "판례"는 거부처분에 대하여 집행정지를 결정하더라도 행정청에게 재처분의무가 직접 발생하지 않으므로 신청의 이익이 없어 부적법하다고 본다. 따라서 반려처분에 대한 집행정지는 허용되지 않는다.

(2) 민사상 가처분의 준용 여부

- 행정소송법상 임시의 지위를 정하는 민사상 가처분의 준용 여부에 대하여, "판례"는 행정소송의 특수성을 고려할 때 집행정지 외에 가처분 제도는 준용될 수 없다는 입장이다.

3. 본안판단 및 인용판결의 효력

(1) 반려처분의 실체법적 위법성

- "노조법 제2조 제4호 라목 단서"는 해고된 자가 부당노동행위 구제신청을 하여 중노위 재심판정이 있기 전까지는 근로자 아닌 자로 해석해서는 안 된다고 규정한다. 이에 부합하는 규약을 이유로 한 반려는 위법하다.

(2) 취소판결의 기속력에 따른 의무

- 취소판결이 확정되면 "행정소송법 제30조 제2항"에 따라 피고 행정청은 판결의 취지에 맞게 이전 신청에 대해 다시 처분을 해야 하는 재처분의무를 부담한다.

III. 사안의 적용

1. 소송요건 및 가구제의 적용

(1) 대상적격과 원고적격

- 乙의 반려행위는 甲이 조직한 노동조합의 법적 지위 획득을 배제하므로 처분성이 인정된다. 소송당사자는 비법인사단인 노동조합 또는 대표자 甲이 되며 원고적격 역시 충족한다.

(2) 가구제 신청의 기각

- 반려처분은 거부처분에 해당하므로 행정소송법상 집행정지는 소의 이익이 없어 허용되지 않으며, 민사상 가처분의 준용 역시 부정되므로 가구제를 통한 임시 구제는 불가능하다.

2. 본안 및 확정판결 효력의 적용

(1) 반려처분의 위법성

- A사 노동조합의 규약은 "노조법 제2조 제4호 라목 단서"에 부합하므로 조합원 자격에 흠결이 없다. 따라서 이를 이유로 행해진 乙의 반려처분은 실체상 위법하므로 법원은 반려처분 취소판결을 내려야 한다.

(2) 乙의 재처분의무 이행

- 취소소송에서 인용판결이 확정되면 피고인 乙은 판결의 기속력에 따라 지체 없이 설립신고서를 수리하고 설립신고증을 교부해야 하는 재처분의무를 이행하여야 한다.

IV. 결론

- 甲이 제기하는 설립신고 반려처분 취소소송은 대상적격과 원고적격을 충족하여 적법하며, 본안심리 결과 乙의 반려처분은 실체법상 위법하므로 법원은 취소판결을 선고해야 한다. 취소판결이 확정되면 乙은 기속력에 따른 재처분의무를 부담하므로 지체 없이 설립신고증을 교부해야 하며, 불이행 시 간접강제를 통해 이행을 강제할 수 있으므로 취소소송은 甲에게 실효성 있는 구제수단이 된다.